

《【문제12.1】

<사례>

A, B, C 세 사람은 공동으로 식당을 운영하기 위하여 동업계약을 체결하고 `행복식당`이라는 명칭을 정하였다. 이들은 식당 운영에 필요한 자재를 공급 받았으나 그 대금을 지급하지 못하고 있다. 자재 공급업자인 丁은 `행복식당` 또는 동업자들을 상대로 소를 제기하여 대금을 회수하고자 한다.

또한, 위 동업자들은 식당 인근의 공사 현장에서 발생하는 소음으로 인해 영업에 큰 차질을 빚게 되자, 공사 업체인 戊를 상대로 손해배상청구의 소를 제기하기로 하였다. 이들은 소송의 효율성을 위해 동업자 중 1인인 A를 소송수행자로 정하여 소를 제기하고자 한다.

丁이 `행복식당` 자체를 피고로 하여 소를 제기할 수 있는지 여부를 민법상 조합의 당사자능력 관점에서 판단하고, A가 동업자들을 대표하여 戊를 상대로 소를 제기하기 위해 필요한 민사소송법상 요건 및 그 효과에 대하여 설명하시오.》

<문제12.1> 민법상 조합의 당사자능력 및 선정당사자 제도의 요건과 효과

I. 문제의 제기

- 사안에서 A, B, C가 공동으로 식당을 운영하는 동업관계에 있고, 자재대금채권자인 丁이 행복식당 또는 동업자들을 상대로 소를 제기하려 하며, 동업자들이 A를 소송수행자로 정하여 손해배상청구소송을 제기하려는 상황이다. 쟁점으로 <민법상 조합의 당사자능력 인정 여부와 선정당사자 제도에 따른 소송수행의 요건 및 그 효과>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 조합의 당사자능력과 선정당사자에 의한 소송수행의 허용 요건 및 법적 효과를 설명한다.

II. 민법상 조합의 당사자능력

1. 원칙 : 당사자능력의 부정

(1) 조합의 실체

- 민법상 조합은 2인 이상이 상호 출자하여 공동사업을 경영할 것을 약정함으로써 성립하는 계약 관계에 불과하다. 따라서 조합은 법인격이 없으며, 원칙적으로 "민사소송법 제51조·제52조"에 따른 당사자능력이 인정되지 않는다.

(2) 소송 수행 방식

- 조합의 채권자나 채무자는 조합원 전원을 공동원고 또는 공동피고로 하여 소를 제기하여야 한다. 이는 조합 재산이 조합원의 합유에 속하기 때문에 발생하는 소송법적 결과다.

2. 판례의 태도

(1) 비법인사단과의 구별

- "판례"는 단체의 실체가 사단적 형태를 갖추고 대표자가 정해져 있는 등 비법인사단("민사소송법 제52조")으로 볼 수 있는 경우에는 당사자능력을 인정한다. 그러나 단순한 동업 계약에 기초한 민법상 조합에 대해서는 일관되게 당사자능력을 부정하고 있다.

(2) 행복식당의 경우

- 사안의 행복식당은 A, B, C의 동업 계약에 의해 운영되는 단체이므로, 특별한 사단적 실체가 증명되지 않는 한 민법상 조합에 해당한다. 따라서 丁은 행복식당 자체를 피고로 할 수 없고, 동업자 A, B, C 전원을 공동피고로 하여 소를 제기하여야 한다.

III. 선정당사자 제도

1. 의의 및 취지

- 선정당사자란 공동의 이해관계를 가진 다수의 사람 중에서 그들을 대표하여 소송을 수행하기 위해 선정된 자를 말한다. 이는 다수당사자 소송의 복잡함을 피하고 소송 경제를 도모하기 위한 제도다.

2. 요건

(1) 공동의 이해관계

- 선정자와 피선정자 사이에 소송물이 공통되거나 소송의 목적이 되는 권리·의무가 같은 법률상 또는 사실상의 원인에 바탕을 두고 있어야 한다. 사안의 동업자들은 공사 소음으로 인한 영업권 침해라는 동일한 사실관계에 기초한 손해배상청구권을 가지므로 공동의 이해관계가 인정된다.

(2) 다수자의 존재

- 선정자는 여러 명이어야 하며, 이들이 피선정자(선정당사자)를 선임해야 한다.

(3) 피선정자의 자격

- 선정당사자는 공동의 이해관계를 가진 당사자 중에서 선정되어야 한다. 동업자 중 1인인 A는 당사자 중 한 명이므로 피선정자 자격이 있다.

3. 선정의 방법과 시기

- 선정은 서면으로 증명해야 하며, 소송 계속 전후를 불문하고 가능하다. 또한 심급마다 선정할 수도 있고 전 소송을 통틀어 선정할 수도 있다.

IV. 선정의 효과 및 소송수행

1. 선정자의 지위

- 선정이 완료되면 선정자들은 소송에서 탈퇴하게 되며, 소송의 당사자 지위를 상실한다. 따라서 이들은 별도로 소를 제기하거나 소송에 직접 참여할 수 없다.

2. 선정당사자의 권한

(1) 소송수행권의 독점

- 선정당사자는 선정자들을 위하여 일체의 소송행위를 할 권한을 갖는다. 여기에는 소의 취하, 화해, 포기, 인낙 등 처분권 행사가 포함되나, 선정자들이 권한을 제한한 경우에는 그에 따라야 한다.

(2) 판결의 효력(기판력)

- 선정당사자가 받은 판결의 효력은 "민사소송법 제218조 제3항"에 따라 선정자 전원에게 미친다. 따라서 판결 확정 후 선정자들은 동일한 사안으로 다시 소를 제기할 수 없다.

V. 사안의 적용

1. 丁의 소 제기

- 丁은 민법상 조합인 행복식당을 피고로 삼을 수 없다. “판례”에 따라 당사자능력이 없는 조합을 상대로 한 소는 부적법각하 대상이 되므로, 丁은 동업자 A, B, C를 공동피고로 하여 소를 제기하여야 한다.

2. A의 선정당사자 소송

- 동업자 B와 C가 A를 선정당사자로 선정하는 서면을 제출한다면, A는 동업자 전체를 대표하여 戊를 상대로 소를 제기할 수 있다. 이 경우 B와 C는 소송에서 탈퇴하며, A가 얻은 판결의 결과는 B와 C에게도 귀속된다. 이는 변호사 대리의 원칙을 잠탈하지 않으면서도 다수자의 소송 편의를 도모하는 적법한 방식이다.

VI. 결론

- 민법상 조합은 당사자능력이 없으므로 조합 자체를 피고로 할 수 없으나, 조합원들이 선정당사자 제도를 이용하는 것은 가능하다. A가 적법하게 선정당사자로 선임된다면 동업자들의 공동 이해관계를 효율적으로 실현할 수 있으며, 그 판결의 효력은 동업자 전원에게 미치게 된다.